

《【문제1】 부작위 위법확인소송에 대해 논하시오. (50점)》

<문제1> 부작위위법확인소송의 의의, 특징, 소송요건, 판결의 효력

I. 문제 제기

- 부작위위법확인소송은 행정청의 위법한 부작위 상태를 확인하여 행정청에게 재처분 의무를 부과함으로써 국민의 권리 구제를 도모하는 것을 목적으로 하며, 그 법적 구조와 요건에 있어 다른 항고소송과 구별되는 특징을 가진다. 이하에서는 "행정소송법"상 항고소송 중 하나인 부작위위법확인소송에 대하여 그 의의, 특수한 법적 성격, 소송요건, 그리고 판결의 효력을 중심으로 상세히 논한다.

II. 부작위위법확인소송의 의의

- 부작위위법확인소송은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 부작위(不作爲)가 위법하다는 것을 확인하는 소송이다. ("행정소송법 제4조 제3호") 이는 행정청의 무응답 상태, 즉 침묵으로 인해 국민의 권리 침해가 발생하는 경우에 인정되는 구제 수단이다.

III. 부작위위법확인소송의 특징

- 부작위위법확인소송은 그 성격상 취소소송과는 다른 다음과 같은 특수성을 가진다.

1. 형식적 당사자소송성

- 이 소송은 외형상 행정청을 피고로 하는 항고소송에 해당하지만, 실질적으로는 행정청의 처분 의무 이행을 간접적으로 강제한다는 점에서 실질적인 당사자소송의 성격을 일부 가진다. 이는 행정청의 공법상 의무 이행을 다룬다는 점에서 당사자소송과 유사성을 띤다.

2. 간접적 권리 구제

- 이 소송은 부작위 상태에 대하여 위법성을 선언하는 확인소송의 성격을 가진다. 법원이 직접 처분을 하도록 명령하는 이행소송의 성격은 가지지 못하며, 단지 부작위의 위법성을 확인하여 행정청에 재처분 의무 ("행정소송법 제30조 준용")를 발생시켜 간접적으로 국민의 권리 구제를 도모한다.

3. 처분성을 요하지 않음

- 취소소송의 대상이 되는 것은 처분등이지만, 부작위위법확인소송의 대상은 행정청의 부작위(처분을 하지 아니한 상태) 그 자체이다. ("행정소송법 제2조 제1항 제2호") 따라서 대상적격 판단 시 부작위 자체에 처분성이 요구되지 않는다. 오히려 부작위는 처분이 부존재함을 전제로 한다.

IV. 부작위위법확인소송의 소송요건

- 부작위위법확인소송이 적법하게 제기되기 위해서는 다음과 같은 소송요건을 충족해야 한다.

1. 대상적격 (부작위의 존재)

(1) 의의

- 부작위위법확인소송의 대상적격은 행정청의 부작위가 법률상 정의된 요건을 충족하는 경우에 인정된다.

① 행정청의 처분 의무

- 부작위가 성립하기 위해서는 행정청이 당사자의 신청에 대하여 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있어야 한다. 이 의무는 수익적 처분 의무뿐만 아니라, 침익적 처분 또는 확인적 처분을 할 의무까지 포함한다.

② 상당한 기간의 경과

- 신청에 대한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 발생한 후 상당한 기간이 경과했음에도 처분이 없어야 한다. 상당한 기간은 관련 법령의 처리 기간, 처분의 성질, 신청의 복잡성 등을 고려하여 사회 통념에 따라 개별적으로 판단된다.

③ 처분 부존재

- 신청에 대한 아무런 처분이 존재하지 않는 상태여야 한다. 만약 거부처분이 내려진 경우, 이는 부작위가 아닌 소극적 처분으로 간주되어 부작위 상태가 해소되고 취소소송의 대상이 된다.

(2) 판단 기준

① 법규상 신청권

- 처분 의무의 근거는 법규에서 도출되는 신청권이다. 관계 법령이 신청권자에게 처분을 요구할 수 있는 권리를 명시적으로 또는 묵시적으로 부여하고 있는 경우에 인정된다.

② 조리상 신청권

- 관계 법령에 명시적인 신청권 규정이 없더라도, 행정청의 처분이 국민의 법률상 지위에 불안정한 영향을 미치거나 공익상 필요한 경우 등 조리(條理)에 의해 신청권이 인정될 수 있다.

③ 재량행위의 부작위

- 재량행위의 경우에도 신청권이 인정될 수 있으며, 행정청이 재량을 행사하지 않고 무응답으로 일관하는 부작위는 위법확인 대상이 된다. 다만, 본안 심리 시에는 위법성 판단이 재량권 일탈·남용 여부가 아닌 재량권 행사의무 위반 여부에 초점을 맞춘다.

2. 원고적격

(1) 의의

- 부작위위법확인소송의 원고적격은 부작위로 인하여 법률상 이익을 침해당한 자에게 인정된다. ("행정소송법 제36조", "제12조" 준용)

(2) 판단 기준

- 원고적격이 인정되기 위해서는 부작위의 대상이 되는 신청된 처분에 대하여 신청인이 법률상 이익을 가지고 있어야 한다. 즉, 처분이 내려졌을 경우 그 처분으로 인해 법률상 이익을 얻거나 침해당할 가능성이 있는 자여야 하며, 단순한 사실상의 이익만으로는 부족하다.

3. 피고적격

- 부작위위법확인소송의 피고는 부작위의 주체인 행정청이다. ("행정소송법 제38조", "제13조" 준용) 이는 처분취소소송과 동일하게 대외적으로 처분 명의를 표시할 권한을 가진 행정기관의 장을 의미한다.

4. 협의의 소의 (권리보호의 필요)

(1) 의의

- 협의의 소익은 소송을 통해 부작위의 위법성을 확인받을 실질적인 이익이 있는지에 관한 요건이다. ("행정소송법 제36조", "제12조" 준용)

## (2) 판단 기준

### ① 부작위 상태의 지속

- 소송 제기 이후에도 부작위 상태가 해소되지 않고 지속되어야 한다. 행정청이 소송 중 신청에 대한 거부처분이나 인용처분을 하는 경우 부작위 상태가 해소되므로 원칙적으로 소익이 소멸한다. 다만, 거부처분의 위법성을 다투기 위해서는 소의 종류를 취소소송으로 변경하여야 한다.

### ② 예외 (소의 이익 유지)

- 부작위 상태가 해소되어 처분이 내려진 경우에도, 그 처분이 위법하여 다시 부작위로 돌아가거나, 확인 판결을 통해 회복될 수 있는 법률상 이익이 남아 있는 경우에는 예외적으로 소익이 유지될 수 있다.

### ③ 처분을 할 수 있는 법률상 가능성

- 부작위위법확인소송은 행정청의 재처분 의무 이행을 목적으로 하므로, 소송 제기 시점 이후에도 행정청이 처분을 할 수 있는 법률상 가능성이 있어야 소익이 인정된다. 예를 들어, 신청의 대상이 되는 물건이 멸실된 경우 등은 소익이 부정될 수 있다.

## 5. 제소기간

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 계속되는 한 위법 상태가 지속되는 것으로 보아, 원칙적으로 취소소송과 같은 제소기간의 제한이 없다. ("행정소송법 제20조"는 부작위위법확인소송에 준용되지 않음)

### (1) 행정심판을 거치지 아니한 경우

- 부작위는 계속되는 것이므로 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않는다고 보는 것이 타당하다.

### (2) 행정심판을 거친 경우

- 행정심판을 거친 경우에는 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 제기해야 한다. ("행정소송법 제20조") 이는 불복 기간을 정함으로써 법적 안정성을 확보하기 위함이다.

## 6. 행정심판 전치주의

### (1) 의의

- 부작위위법확인소송은 취소소송의 규정이 준용되지만, 그 대상이 부작위이므로 행정심판을 거치지 않고 소송을 제기하는 것이 원칙이다.

### (2) 내용

- "행정소송법 제38조"에 따라 부작위위법확인소송에는 취소소송의 규정이 준용되지만, "제18조"(행정심판 전치)는 준용되지 않는다는 명시적인 규정은 없다. 그러나 부작위 상태에서는 행정심판의 의무적 전치주의가 적용되지 않는다는 것이 일반적인 견해이며, 법원의 태도이다. 다만, 개별 법률이 부작위에 대한 행정심판을 명시적으로 요구하는 경우에는 필요적 전치가 적용될 수 있다.

## V. 부작위위법확인판결의 효력

### 1. 확인 효력

- 부작위위법확인판결은 행정청의 부작위 상태가 위법함을 확정하는 효력을 가진다. 이 효력은 부작위가 위법하다는 점에 대한 기판력을 발생시키며, 향후 동일한 부작위 상태에 대한 다툼을 차단한다.

### 2. 기속력

#### (1) 의의

- 부작위위법확인판결이 확정되면, 그 판결의 효력은 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 기속한다. ("행정소송법 제38조 제2항", "제30조 제1항" 준용) 이는 소송의 실효성을 담보하는 핵심적인 효력이다.

#### (2) 내용

- 행정청은 판결의 취지에 따라 재처분 의무를 부담하게 된다. 즉, 행정청은 지체 없이 판결의 취지에 따른 적법한 처분을 해야 한다. 이 재처분 의무는 행정청이 위법 사유를 제거하고 다시 처분을 해야 함을 의미하며, 반드시 신청을 인용해야 할 의무를 의미하는 것은 아니다.

#### (3) 실효성 확보

- 부작위위법확인판결의 실효성은 간접 강제 제도를 통해 확보된다. ("행정소송법 제34조") 행정청이 재처분 의무를 이행하지 않을 경우, 법원은 당사자의 신청에 따라 배상금 지급을 명할 수 있으며, 이는 행정청의 처분을 간접적으로 강제하는 수단이 된다.

## VI. 결론

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위로 인한 국민의 권리 침해를 구제하기 위한 중요한 행정소송 유형이다. 그 소송요건으로는 행정청의 법률상 처분 의무와 상당한 기간 경과에도 불구하고 처분이 없는 부작위의 존재(대상적격), 법률상 이익 있는 자(원고적격), 부작위의 주체인 행정청(피고적격), 소의 이익, 그리고 필요적 행정심판 전치주의 준수 등이 있다. 부작위위법확인판결은 해당 부작위의 위법성을 확인하고 행정청에게 재처분 의무를 부과하며, 간접강제를 통해 그 실효성을 확보할 수 있다. 이는 적극적인 행정 작용을 이끌어내어 국민의 권익을 실질적으로 보호하는 데 기여한다.